

1501114-12.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE INEXISTENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. Em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso de policiais na residência do suspeito, mesmo sem mandado de busca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-12.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

REBERT WILIAN LIMA MATTOS E OUTRO

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

JEFERSON COSTA ROBERTO e REBERT WILIAN LIMA MATTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, às 15h, foram surpreendidos associados com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Também consta que JEFERSON COSTA ROBERTO e REBERT WILIAN LIMA MATTOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, às 15h, na Rua Maria Aparecida Ferreira da Silva, quadra 2, Jardim Petrópolis, nesta cidade e Comarca de Bauru, o réu GUILHERME, previamente associados, foram surpreendidos com 9,3 g de entorpecente conhecido como crack, divididos em 33 porções, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que JEFERSON COSTA ROBERTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 2º da Lei nº 12.683/2012, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2022, no período da tarde, na Rua Carlos Linhares Roda, nº 31-02, Quinta da Bela Olinda, nesta cidade e Comarca de Bauru, ocultou a origem de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

A denúncia foi oferecida às fls. 1/6.

A decisão de fls. 185/187 recebeu a denúncia, determinou a notificação e citação dos réus e designou audiência de instrução, debates e julgamento.

Os réus foram citados (réu JEFERSON: fl. 219; réu REBERT: fl. 220) e apresentaram defesa prévia (réu JEFERSON: fls. 202/210; réu REBERT: fl. 231).

A decisão de fls. 252/253 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução processual, procedendo-se à oitiva de duas testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa e ao interrogatório dos réus (fls. 333/335-midia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, para condenação dos réus apenas pelo delito de tráfico de drogas (fls. 354/365).

Em outro ângulo, a Defesa do réu JEFERSON preliminarmente rogou pelo reconhecimento da nulidade do processo, uma vez que as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, tendo em vista a violação de domicílio. Quanto ao mérito, assinalou que nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, assim como não restou demonstrado qualquer ânimo associativo, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e autorização para recorrer em liberdade (fls. 385/394).

No mesmo sentido, a Defesa do réu REBERT pugnou pela absolvição diante da ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, sustentou e pleiteou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com consequente absolvição ante a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Ainda, rogou pela fixação da pena-base no mínimo legal, em regime semiaberto, e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 398/403).

É o relatório.
DECIDO.

De início, repilo a preliminar ventilada pela Defesa do réu JEFERSON quanto à nulidade das provas, sob o argumento de violação de domicílio, ante a existência de estado flagrancial estabelecido anteriormente, cancelando a atuação policial. No caso concreto, os policiais abordaram o corréu REBERT em via pública e localizaram as porções de estupefaciente em poder dele e também escondidas em um cano, momento em que ele afirmou comercializar drogas de propriedade do réu JEFERSON, o qual estava no imóvel em frente ao local da abordagem; ato contínuo, o réu JEFERSON autorizou o ingresso dos policiais na residência, de propriedade de seus sogros, local no qual apenas foram encontradas as quantias em dinheiro. Houve igualmente autorização da entrada dos militares em sua própria casa, situada no bairro Quinta da Bela Olinda, onde foi localizada a importância de R\$ 2.589,00, razão pela qual não há se falar em violação de garantia fundamental, uma vez que as drogas foram encontradas na via pública e, na sequência da diligência, localizadas quantias em dinheiro nos imóveis, destacando-se que o réu JEFERSON autorizou o acesso dos agentes. Alias, caso assim não procedessem, estariam os agentes públicos fadados a responder por prevaricação, diante de eventual omissão do dever de agir.

Outrossim, apenas por amor aos debates, cabe acentuar que o delito em análise se trata de crime permanente, o qual autoriza a entrada policial no domicílio, com ou sem mandado judicial, em evidente estado de flagrância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE INEXISTENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. Em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso de policiais na residência do suspeito, mesmo sem mandado de busca e apreensão, pois a regra constitucional da inviolabilidade do lar não socorre agente em situação flagrancial. [...] (TJMG. 4ª Câmara Criminal. Apelação Criminal 1.0290.18.004394-2/001. Relator: Des. Fernando Caldeira Brant. Data do julgamento: 16 de outubro de 2019) (destaquei)

Ainda, cabe ressaltar a sólida jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. Habeas corpus não conhecido. (STJ. Quinta Turma. HC 309.567/CE. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Data do julgamento: 3 de abril de 2018)

De mais a mais, ainda a título de argumentação, nenhum direito fundamental é absoluto. O princípio da proporcionalidade deve ser levado em consideração quando houver conflito entre duas garantias constitucionais e, se observado um confronto entre a inviolabilidade domiciliar e a segurança pública, deve esta preponderar.

Por consequência, não há se falar em provas produzidas por meios ilícitos, afastando-se a preliminar arguida.

Alijando a matéria preliminar aventada, passo à análise do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelos corréus, como também do crime de “lavagem de dinheiro” pelo réu JEFERSON.

As provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência parcial do pedido inicial apenas para condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes e, nesse ponto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 7, boletim de ocorrência de fls. 16/20, auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo de constatação provisória de fls. 24/29 e laudo toxicológico definitivo de fls. 138/142, além da prova oral produzida em Juízo.

A imputação da autoria do delito aos réus é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

O réu REBERT negou o delito. Disse que havia acabado de chegar ao local quando foi abordado pelos policiais, os quais apontaram arma de fogo em sua direção, procederam à abordagem e fizeram questionamentos acerca de drogas, momento em que afirmou que nada possuía. Aduziu que um militar foi à residência situada do outro lado da rua e abordou o corréu JEFERSON. Acrescentou ter afirmado aos policiais que apenas conhecia o corréu JEFERSON da região. Falou que os militares encontraram droga em um cano, porém negou a propriedade e esclareceu que portava somente uma porção de cocaína, destinada ao consumo próprio. Mencionou ter sido conduzido à residência do corréu JEFERSON, onde os policiais encontraram quantia em dinheiro.

Negou portar três pedras de crack e ter apontado o corréu JEFERSON como proprietário dos estupefacientes (fls. 333/335-mídia).

Por sua vez, o réu JEFERSON narrou que, na data dos fatos, estava na residência de seus sogros arrumando um veículo quando ouviu barulho de freada e saiu para ver o que havia acontecido, momento em que observou o corréu REBERT sendo abordado e algemado pelos policiais; ato contínuo, o militar apontou arma de fogo em sua direção e efetuou a abordagem, afirmando que havia notícia da prática de tráfico no local e pedindo autorização para ingressar na residência, tendo concordado com a entrada. Contou que no imóvel apenas foi encontrada uma quantia em dinheiro, tendo afirmado acreditar que era de seu sogro, no entanto, com a negativa deste, esclareceu que poderia ser do corréu REBERT, já que ele constantemente ingressava na casa. Asseverou que foi informado pelo policial que o corréu REBERT teria afirmado que vendia drogas a seu mando, momento em que negou e pediu ao militar para que trouxesse o corréu REBERT a fim de esclarecer os fatos. Reportou ter indicado o endereço de sua residência aos militares, embora eles já soubessem, bem como informado que no imóvel havia dinheiro proveniente de venda recente de uma motocicleta sem documentação. Explicou que os policiais retornaram ao local da primeira abordagem e arrombaram, com um alicate grande, o cadeado do estabelecimento comercial vizinho ao imóvel de seus sogros, tendo derrubado diversas garrafas de bebida. Disse que havia populares na rua no momento da abordagem e não presenciou os militares procurando drogas em um cano (fls. 333/335-mídia).

O policial militar Cristiano Henrique dos Santos relatou que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento em local conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes quando observou o réu REBERT agachado na sarjeta e a presença de outros dois indivíduos, motivo pelo qual procedeu à abordagem do réu REBERT e encontrou, em poder dele, três pedras de crack e quantia em dinheiro; ao verificar o local onde ele estava agachado, localizou, escondida no interior de um cano, sacola contendo outras porções do estupefaciente. Falou que os outros indivíduos se evadiram e não foram abordados. Esclareceu ser prática comum no tráfico manter as drogas escondidas e o vendedor permanecer com poucas porções em mãos. Acrescentou que o réu JEFERSON estava na residência situada defronte ao local de abordagem e, assim que ele saiu do imóvel, o corréu REBERT prontamente afirmou que estava vendendo drogas a mando dele, quando então seu colega de farda abordou o réu JEFERSON, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder dele. Mencionou que o réu JEFERSON autorizou o ingresso na residência, tendo sido localizadas quantias em dinheiro no carro e em um cômodo do imóvel, dentro de um maço de cigarros, momento em que o réu JEFERSON afirmou que o valor era de seu sogro, no entanto este negou a propriedade do dinheiro. Explicou que o réu JEFERSON asseverou que residia naquele imóvel, contudo, por saber que a casa dele era situada no bairro Quinta da Bela Olinda, já que atendeu outra ocorrência envolvendo vizinhos, questionou-lhe, quando então ele confirmou e disse que havia dinheiro em uma estante, proveniente da venda de uma motocicleta, tendo ocorrido a apreensão de cerca de R\$ 2.500,00. Aduziu que havia informação de que os réus atuavam em conjunto na mercancia ilícita, sendo que usuários costumam noticiar de quem adquiriram as drogas. Contou que policiais vistoriaram o estabelecimento comercial da sogra do réu JEFERSON, todavia não soube como seu o ingresso no imóvel (fls. 333/335-mídia).

No mesmo sentido, o policial Hector Nogueira Rodrigues narrou que, em patrulhamento pelo Bairro Buritis, onde há bastante reclamação dos moradores acerca da prática do tráfico de drogas, notou um indivíduo agachado na via pública e outros próximos, aparentando ser usuários, motivo pelo qual procedeu à abordagem e encontrou com o primeiro, o réu REBERT, quantia em dinheiro e três porções de crack no bolso de sua vestimenta, tendo ele imediatamente admitido que iria comercializar entorpecente aos outros indivíduos, bem como afirmado que trabalhava para o corréu JEFERSON, que estava próximo ao portão de uma residência situada em frente; ato contínuo, seu colega de farda vistoriou o local onde o réu REBERT estava agachado e encontrou, em

um encanamento, 30 pedras de crack semelhantes àquelas localizadas com o réu REBERT. Disse que efetuou a abordagem do réu JEFERSON, apelidado de "Ninho", conhecido de data anterior pela prática da mercancia ilícita, e ele franqueou o ingresso naquela residência, tendo sido encontradas apenas quantias em dinheiro no interior de um veículo e em um maço de cigarros que estava em um cômodo do imóvel, momento em que o réu JEFERSON afirmou que tais importâncias eram de seu sogro, no entanto este negou e então aquele disse que possivelmente era do corréu REBERT, pois ele sempre entrava na casa, embora não possuísse vínculo de amizade. Reportou que o réu JEFERSON, ao ser questionado sobre sua residência própria, noticiou que não guardava nada de ilícito no imóvel e, após vistoria no local, houve apreensão da quantia aproximada de R\$ 2.500,00, tendo ele justificado ser oriunda da venda de uma motocicleta. Asseverou que o local onde os réus foram abordados é conhecido como ponto de tráfico e populares já haviam lhe dito que ambos atuavam em conjunto. Não se recordou acerca de apreensão de porção de cocaína. Falou que no local há um estabelecimento de propriedade da sogra do réu JEFERSON, não sabendo informar como se deu a abertura da porta do imóvel (fls. 333/335-mídia).

Por seu turno, a testemunha de defesa Thiago Fernandes dos Santos falou que é proprietário do estabelecimento comercial onde os policiais ingressaram sem qualquer autorização. Mencionou que, à época dos fatos, o réu JEFERSON havia comercializado motocicletas e uma residência (fls. 333/335-mídia).

Já a testemunha Igor da Silva Silveira contou que o réu JEFERSON é pessoa trabalhadora e confiável (fls. 333/335-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e apreensão das drogas, dão respaldo ao decreto condenatório somente quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades "ter em depósito", "trazer consigo" e "guardar", verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restando demonstrado que o réu JEFERSON tinha em depósito 30 porções de crack e o corréu REBERT trazia consigo 3 pedras de crack e guardava outras 30 porções do mesmo entorpecente.

A negativa dos réus quanto à traficância, bem como no tocante ao estupefaciente apreendido em nada muda o cenário probatório produzido nos autos, pois tudo que foi apurado leva à comprovação do delito descrito na denúncia.

Diversamente do propugnado pelas Defesas, a reconstrução histórica dos acontecimentos, propiciada pela produção probatória, tornou certo o envolvimento dos réus com o tráfico ilícito de entorpecentes.

De fato, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se deu a abordagem e a apreensão do estupefaciente, haja vista que efetuavam patrulhamento em região conhecida como ponto de tráfico, notaram o réu REBERT agachado na via pública, havendo usuários de droga próximos a ele, e então procederam à abordagem, encontrando quantia em dinheiro e 3 pedras de crack no bolso da vestimenta do réu REBERT e outras 30 porções do estupefaciente escondidas em um encanamento onde ele foi visto agachado, momento em que o réu REBERT admitiu a traficância, bem como esclareceu que o corréu JEFERSON era o proprietário da droga, tendo sido apreendidas quantias em dinheiro na casa do réu JEFERSON e no imóvel de seus sogros, não tendo ele comprovado lastro das importâncias. Além disso, cumpre enfatizar que os militares possuíam informações de que os réus atuavam em concurso na mercancia ilícita.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do

procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos agentes revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos militares, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar os réus. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição dos réus.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade e a forma como os produtos foram encontrados (33 pedras de crack), além das quantias em dinheiro encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação

do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização dos réus. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

De se notar que, embora o réu REBERT negue a propriedade do estupefaciente e afirme ser usuário, é certo que tal negativa não passou de uma tentativa da Defesa para desclassificar o delito.

Aliás, a alegação de ser usuário não alija a traficância. Muitos traficantes buscam como meio de defesa a desclassificação da infração penal. E, neste ponto, é importante salientar não ser uma situação excludente da outra. Além disso, o depoimento dos policiais comprovou de forma estreme de dúvidas que o réu praticava o tráfico de drogas.

Por outro lado, no entanto, não merece procedência o pedido no tocante ao crime de associação para o tráfico.

Com efeito, tal delito exige a estabilidade das relações entre os agentes para sua consumação. Ainda, destaca-se a necessidade de haver caráter duradouro e que os agentes estejam ajustados para a finalidade de comercialização de entorpecentes.

No caso ora em análise, malgrado os militares possuíssem informação de que os réus atuavam em conjunto, é certo que a estabilidade e o caráter duradouro não restaram provados, configurando-se apenas um concurso de agentes entre eles. Ainda, há que se ressaltar que a ação policial se deu em decorrência da percepção dos agentes, durante patrulhamento de rotina, da atitude do réu REBERT, agachado em via pública, estando próximos a ele indivíduos usuários de droga, inexistindo diligências anteriores especificamente em relação às atividades eventualmente praticadas pelos réus.

De mais a mais, conquanto a prova produzida pela acusação dê conta do envolvimento do réu JEFERSON com o mundo do tráfico e, por consequência, o vínculo do valor apreendido (total de R\$ 2.940,00) com tal delito, é certo que não foi capaz de demonstrar a prática do crime de "lavagem de dinheiro".

Ora, a Lei nº 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. O delito previsto no artigo 1º da referida Lei caracteriza-se pelo mascaramento de um recurso obtido de origem ilícita, mediante ocultação ou dissimulação. Ocultar significa esconder, encobrir. Dissimular significa ocultar com esperteza, disfarçar, simular. O objeto material é o produto do crime, todavia não basta a constatação de um delito antecedente, é necessário comprovar que esse produto foi ocultado ou dissimulado posteriormente, ou seja, para adequação ao tipo penal é imprescindível a ocultação de um valor inserido no sistema financeiro, por

exemplo, com sua respectiva conversão em ativo lícito, por meio de negócio jurídico simulado.

In casu, apenas restou demonstrado que o réu JEFERSON guardava tais quantias, inexistindo prova no tocante à dissimulação da origem da importância, com a conversão de um ativo ilícito em um ativo lícito e consequente reintrodução na economia com aparência lícita. A jurisprudência pátria é esclarecedora sobre o tema:

[...] 2) A lavagem de dinheiro é entendida como a prática de conversão dos proveitos do delito em bens que não podem ser rastreados pela sua origem criminosa.

3) A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia censura penal autônoma, para além daquela incidente sobre o delito antecedente.

4) O delito de lavagem de dinheiro, consoante assente na doutrina norte-americana (money laundering), caracteriza-se em três fases, a saber: a primeira é a da colocação (placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação da sua origem, que pode ser realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões de obras de arte, dentre outros negócios aparentemente lícitos. Após, inicia-se a segunda fase, de "encobrimento", "circulação" ou "transformação" (layering), cujo objetivo é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. Por fim, dá-se a "integração" (integration) dos recursos a uma economia onde parecem legítimos.

[...]

(Supremo Tribunal Federal. Décimos segundos embargos infringentes na Ação Penal 470/MG. Relator: Min. Luiz Fux, j. 13.03.2014)

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelos réus, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena de forma individualizada:

a) PARA O RÉU JEFERSON COSTA ROBERTO

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 97: processo nº 1512346-60.2018.8.26.0071). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não levam à exasperação da pena.

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, devendo ser mantida a sanção anteriormente fixada.

Ademais, não se pode admitir, in casu, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Com efeito, malgrado o réu tenha cometido o crime em 19 de janeiro de 2022, é certo, todavia, que mencionada agravante apenas deve ser considerada nos casos em que o infrator pratica o crime aproveitando-se de situação de desgraça particular ou calamidade pública. Acerca da matéria, é de fundamental importância destacar a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

"[...] mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois

dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgrasas particulares de alguém. Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro" (Código Penal Comentado, 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Na hipótese dos autos, contudo, nada restou demonstrado no sentido de que o réu tenha se beneficiado ou aproveitado do contexto da pandemia para justamente praticar o delito, como também a calamidade pública do novo coronavírus enfrentada por toda população mundial em nada interferiu nas atividades criminosas do réu.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes do réu, a natureza e a quantidade do entorpecente, bem como porque a prova coligida nos autos demonstrou que o réu não se tratava de traficante de primeira viagem, haja vista que já era conhecido dos meios policiais e foi abordado em um ponto de tráfico, a revelar sua dedicação a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual. Ainda, por amor aos debates, o pretendido privilégio já foi concedido ao réu nos autos do processo nº 1512346-60.2018.8.26.0071.

Dessa maneira, ficam as penas mantidas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

b) PARA O RÉU REBERT WILIAN LIMA MATTOS

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fls. 99/100: processo nº 0004041-69.2015.8.26.0071; fl. 100: processo nº 0026859-44.2017.8.26.0071; fl. 100: processo nº 1511725-92.2020.8.26.0071), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não levam à exasperação da pena.

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal, aumentando-a em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fl. 99: Execução da Pena nº 0002285-24.2019.8.26.0026, referente ao processo nº 0001145-

65.2017.8.26.0594). Assim, majoro a pena em 1/4, ficando, então, estabelecida no montante de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Por outro lado, não se pode admitir, in casu, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Com efeito, malgrado o réu tenha cometido o crime em 19 de janeiro de 2022, é certo, todavia, que mencionada agravante apenas deve ser considerada nos casos em que o infrator pratica o crime aproveitando-se de situação de desgraça particular ou calamidade pública. Acerca da matéria, é de fundamental importância destacar a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

"[...] mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro" (Código Penal Comentado, 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Na hipótese dos autos, contudo, nada restou demonstrado no sentido de que o réu tenha se beneficiado ou aproveitado do contexto da pandemia para justamente praticar o delito, como também a calamidade pública do novo coronavírus enfrentada por toda população mundial em nada interferiu nas atividades criminosas do réu.

Igualmente, não há se falar em confissão espontânea, visto que o réu negou a prática do tráfico de drogas e apenas admitiu que portava uma porção de cocaína destinada ao próprio consumo, porção esta sequer apreendida nos autos.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes e a reincidência do réu, a natureza e a quantidade do entorpecente, bem como porque a prova coligida nos autos demonstrou que o réu não se tratava de traficante de primeira viagem, haja vista que já era conhecido dos meios policiais e foi abordado em um ponto de tráfico, a revelar sua dedicação a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual.

Dessa maneira, ficam as penas mantidas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado (artigo 33, § 2º, "a" e "b", do Estatuto Repressivo), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e a reincidência. Ademais, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Ainda, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo).

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

- a) CONDENAR o réu JEFERSON COSTA ROBERTO à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado;
- b) CONDENAR o réu REBERT WILIAN LIMA MATTOS à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido nos autos (fls. 22/23: importe total de R\$ 3.065,40), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

O réu JEFERSON responde ao processo em liberdade por determinação do c. STJ nos autos do Habeas Corpus nº 746.842/SP (fls. 291/295). Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

De outra banda, o réu REBERT respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pelos antecedentes e reincidência, além das razões já expostas às fls. 108/112, 274/284 e 339/347, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA